

1503405-96.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" para fins de tráfico, cocaína, skunk, maconha, crack, k2/k4 e lança perfume.

Inequívoco, portanto, reconhecer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503405-96.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503405-96.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2039314/2022 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 22949720 - 43º

D.P. CIDADE ADEMAR, 2039314 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VICTOR SALES NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos.

MATHEUS VICTOR SALES NASCIMENTO, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 12h50min, na rua Doutor Carlos de Rezende Enout, altura do nº 610, Parque Doroteia, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 44 porções de cocaína, com peso líquido de 32,9g; 34 porções de Skunk, com peso líquido de 24,6g;

33 porções de maconha, com peso líquido de 210,3g; 55 porções de crack, com peso líquido de 14,4g, 69 porções de K2/K4 (maconha sintética), com peso líquido de 18,6g e 12 frascos contendo 28ml de cloreto de metileno/diclorometano (lança perfume), substâncias essas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica (fls. 01/02).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01), sendo sua custódia convertida em preventiva (fls. 53/55).

Determinação da notificação (fls. 79/81), o réu foi notificado (fls. 103) e ofertou defesa previa (fls. 109/110), sendo recebida a denúncia (fls. 111/113).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia, aplicando-se o privilégio. A defesa, por memoriais, requereu, em síntese, a absolvição do acusado por ilegalidade de prova e insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando-se regime inicial aberto e convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 137/142).

Juntados o documento de fls. 157/165, o Ministério Público se manifestou às fls. 171/173, retificando os debates ofertados, para que não seja reconhecido o privilégio previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

A defesa reiterou as alegações ofertadas em seu debate (fls. 177/181).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de fls. 11 e laudo de fls. 133/136, prova técnica de que se tratavam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu negou a prática do delito. Afirmou, em suma, que havia ido a biqueira buscar drogas para seu consumo. Foi abordado por policiais e respondeu que tinha passagem. Falou que era uma menina que estava traficando, a qual correu ao ver a polícia e deixou um pacote. O policial Marcos não conseguiu pegar a menina. Não conhecia os policiais e os escutou falando que ganhariam um bônus por tê-lo prendido. Negou que estivesse com uma pasta social, levando consigo apenas um pino e porção de uma maconha, além de cinco reais. Não disse para os policiais que estava no local traficando (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

O policial civil Marcos Antônio Pasqualini Filho relatou, em suma, que diligenciaram, em viatura descaracterizada, no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas. Perceberam que o réu estava na entrada da viela, com uma pasta social, o que chamou a atenção. O abordaram e dentro da pasta, encontraram cerca de 250 porções de drogas e trinta reais em dinheiro trocados. O acusado disse que receberia noventa reais por dia pela vida das drogas e que trabalharia das 09h as 21h. O Réu não disse há quanto tempo estava envolvido com a traficância. Encontraram maconha, cocaína, crack, skunk, lança- perfume e k2. (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Márcio Roberto Machado, também policial civil, declarou, em resumo, quem na hora do almoço, estavam em diligência de combate ao tráfico em local conhecido como ponto de venda de drogas. Foram em viatura descaracterizada e Matheus não percebeu sua aproximação. O acusado estava com uma bolsa executiva, dentro da qual encontraram porções de maconha, cocaína, skunk, K2m lança perfume, além de trinta reais

trocados. O réu disse que estava traficando no local desde as 9h e lá ficaria até às 21. Disse que receberia noventa reais pela venda. Não esclareceu há quanto tempo traficava. Não conhecia o réu, que estava sozinho. Não o viram vendendo drogas e o abordaram porque o local é conhecido como ponto de tráfico (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. E não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade de suas declarações. Conquanto o acusado tenha tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não relatou qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Ademais, há que destacar que não se vislumbra ilicitude na prova obtida com a abordagem feita pelos policiais civis, que verificaram que o réu agia de modo suspeito, sendo com ele encontradas drogas, em situação que reputaram indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os depoimentos colhidos, a quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como a forma de acondicionamento de entorpecentes e a localização de dinheiro revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes. Não deve prosperar a declaração do acusado de que a droga com ele encontrada se destinava ao seu consumo.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" para fins de tráfico, cocaína, skunk, maconha, crack, k2/k4 e lança perfume.

Inequívoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, considerando a quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base em 1/6 acima no mínimo legal: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não é caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em tela, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, ausentes as atenuantes. Assim, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. O réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional. Embora o acusado seja primário, os policiais relataram que o mesmo revelou que estava no local cumprindo o turno das 9h as 21h, o que revela que seu envolvimento com a

traficância não foi um fato isolado. Ademais, o mesmo ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido aplicada medida socioeducativa (fls.157/163), hipótese para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal ora analisado. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. MODO INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem negou a aplicação da minorante por entender que a quantidade dos entorpecentes apreendidos (219,8 gramas de maconha e 1,6g de cocaína) e o registro de atos infracionais na adolescência, inclusive análogos ao tráfico de entorpecentes, comprovam a habitualidade delitiva do paciente. Logo, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Esta tem Corte decidido que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. 5. Mantido o quantum da pena do paciente em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, 'b', e 44, I, ambos do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 537.485/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019; sem grifos no original.)

Ainda,

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Prisão em flagrante do apelante na posse de 12 flaconetes de cocaína (20,23g) e de R\$ 117,00, cuja origem lícita não veio delineada. Testemunhos dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante em consonância com os demais elementos de prova. Diligência levada a efeito durante campana em que visualizado quando o réu e um comparsa não identificado, que logrou êxito em fugir, realizavam vendas a terceiros. Negativa judicial do acusado, que se disse simples viciado, que sucumbiu à prova dos autos. Condenação mantida. PENA. Base fixada no mínimo legal. Menoridade relativa que já veio reconhecida pela r. sentença, mas que resultou inócua, a teor da Súmula 231 do STJ. Negada a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, corretamente, pelo envolvimento do apelante quando menor em ato infracional equiparado ao tráfico, tornou-se definitivo o apenamento de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos. Manutenção. (...)

(Apelação Criminal n. 1500899-81.2019.8.26.0575, Rel. Des. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, j. 27.mai.2020).

Destarte, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela, mantendo a pena no patamar fixado.

Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014).

In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado para o tráfico. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º do CP). Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal, para CONDENAR o réu MATHEUS VICTOR SALES NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não surgiram elementos que amparassem a decretação da sua prisão preventiva.

Considerando o teor dos documentos de fls. 157/165, proceda a serventia sua recategorização para sigiloso.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA